

1500377-45.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038132/2022 - DISE-

DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 22924129 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 13/22/501 -

DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2038132 - DISE- DEL.SEC.FRANCO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500377-45.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500377-45.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038132/2022 - DISE-

DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 22924129 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 13/22/501 -

DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2038132 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

RALF RODRIGUES DA ROCHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Vistos.

RALF RODRIGUES DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta de 12h30, na trilha de terra paralela à linha de trem localizada na Avenida São Paulo, 629, Jardim Eliza, Francisco Morato/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e guardava, dentro de um estojo porta-óculos: a) trinta porções de cocaína, com massa líquida total de

aproximadamente 19,5g (dezenove gramas e cinco decigramas); b) cinco porções de maconha, com massa líquida total de aproximadamente 6,8g (seis gramas e oito decigramas); e c) trinta e cinco porções de "crack", com massa líquida total de aproximadamente 6,3g (seis gramas e três decigramas).

Recebida a denúncia em 08 de março de 2022 (fls. 99). O réu foi citado (fls. 143) e apresentou defesa prévia (fls. 148). Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 160/161).

Na instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao término, o réu foi interrogado.

Após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, em debates o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação de pena acima do mínimo e regime inicial fechado de cumprimento.

O Douto Defensor, por sua vez, requereu às fls. 193/211 o reconhecimento da nulidade do flagrante e da atipicidade da conduta. No mais, sustentou que as provas são insuficientes para uma condenação e que, neste caso, deveria haver a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Pugnou pela fixação de regime aberto de cumprimento de pena, com substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com direito a apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Preliminarmente, não merece guarida a tese de absolvição do réu pelo reconhecimento da figura do flagrante preparado, que é ilegal e caracteriza o crime impossível, pois impede o resultado lesivo.

No flagrante preparado, o agente é induzido à prática do crime por aquele que pretende o flagrante. Por sua vez, o flagrante esperado não é ilegal, e caracteriza-se quando aquele que pretende o flagrante tão somente aguarda a prática do crime, sem induzir o agente a praticá-lo. No caso em apreço, resta evidente que não se trata de flagrante preparado, considerando que o réu já vinha praticando o delito e não foi induzido à prática delituosa.

A ação merece ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do auto de exibição e apreensão (fls. 12), dos laudos de constatação preliminar (fls. 15/17) e definitivo (fls. 111/113) e, por fim, pela prova oral colhida em regular instrução.

A autoria também é certa, nos termos abaixo consignados.

Na fase extrajudicial, o réu admitiu a prática dos fatos a si imputados (fls. 07).

Interrogado perante o contraditório, o réu mudou sua versão dos fatos. Disse que pegou R\$ 100.00 e foi ao local dos fatos para adquirir entorpecentes, já que era usuário e tinha acabado de sair de uma clínica. Declara que comprou 10 pedras de crack, 2 porções de maconha e 1 de maconha. Após feita a aquisição, chegou um outro usuário e pediu entorpecentes. O interrogando pegou o dinheiro deste usuário e entregou ao traficante, bem como intermediou a entrega da droga, ao que este usuário começou a puxar o interrogando de forma violenta. Esclarece que reagiu porque até aquele momento não sabia que este suposto usuário era na verdade um policial. Enquanto isso, o traficante fugiu. Afirma que não houve interesse do

policial em correr atrás do traficante. É amasiado, tem filhos e trabalha numa tapeçaria com a mãe. Adicionou que já foi condenado por tráfico e que esteve internado por dependência de drogas.

A negativa de autoria em juízo foi rechaçada pelos demais elementos constantes dos autos. Senão vejamos.

O policial civil Clodoaldo relatou em juízo que, no dia dos fatos, foi ao local dos fatos, um conhecido ponto de venda de entorpecentes. Ali adentrou descaracterizado e viu o réu em atitude suspeita com um porta óculos. Realizou a abordagem e o réu resistiu, tendo havido inclusive luta corporal. Afirma que no porta óculos foram encontrados os entorpecentes apreendidos e que, depois de detido, o réu admitiu que estava ali traficando. Esclarece que a abordagem se deu pela conduta do réu, que ficava observando o entorno em atitude comum à traficância.

A seguir, o policial Felipe descreveu a dinâmica dos fatos de forma similar.

A narrativa dos fatos tecida pelos policiais em juízo não difere daquela constante de suas oitivas na fase policial.

Não há razão para desqualificar a prova policial, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São agentes do Estado, razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção. Na espécie, a narrativa tecida por ambos é coesa, coerente, uniforme e detalhada. É o suficiente para lhes conferir importante valor probatório. No mesmo sentido, converge a lição diária de nossos tribunais:

Prova criminal - Testemunhal - Tráfico de entorpecentes - Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão - Credibilidade - Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

O réu não arrolou testemunhas de defesa.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, o réu não trouxe aos autos prova hábil a comprovar que os fatos não se deram da forma narrada na denúncia, ônus que lhe incumbia por força do art. 156 do Código de Processo Penal.

O crime de tráfico ilícito de drogas é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma na outra desde a sua produção até a sua entrega a consumo, ainda que de forma gratuita. A quantidade de droga apreendida - embora não expressiva - era relevante e se mostra suficiente, dentro do contexto probatório, para colocar em risco a saúde pública e a segurança da comunidade.

Por fim, vale consignar que o decreto condenatório não se ampara exclusivamente nos

depoimentos colhidos em sede administrativa, e sim em todo o contexto probatório, corroborando a prova produzida em juízo a sucessão de fatos tal como foram apurados e narrados em sede policial, todos coesos no mesmo sentido.

Dosimetria da pena

Passo a dosar a pena, de acordo com o critério trifásico que informa o Código Penal.

Na primeira fase, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base ligeiramente acima do piso legal: em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Para tanto, registro que o réu não agiu com culpabilidade elevada à espécie delitiva, mas ostenta uma condenação criminal pelo mesmo delito, ainda que não apta a gerar reincidência (fls. 63).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, deixo de aplicar o reduto de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, posto que o réu, embora tecnicamente primário, ostenta antecedentes criminais e é incompatível a concessão da benesse legal para quem volta a incorrer na atividade delitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, bem como à observância do artigo 42, da Lei 11.343/06, haja vista a pena fixada.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo vigente no dia do fato, corrigido em sede de execução, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por não haver provas nos autos de que o réu possua boa situação financeira.

Pela pena fixada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco a concessão de sursis.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO RALF RODRIGUES DA ROCHA às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar multa de 550 dias-multa, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Em que pese a alteração legislativa levada a efeito com a publicação da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, em especial da redação do seu art. 1º e 2º, deixo de aplicá-la em sua integralidade.

Ora, trata-se de dispositivos manifestamente inconstitucionais, posto que violam os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.

O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal. A quantidade da pena deve guardar proporção com a importância do bem jurídico

tutelado e a gravidade da ofensa. Por isso, cada tipo penal prevê quantidade mínima e máxima de pena e, em alguns casos, espécies distintas de sanções penais, que podem ser aplicadas, dependendo do caso, alternativa ou cumulativamente.

Na etapa judiciária, caberá ao juiz, à vista da infração cometida, escolher a pena que será aplicada dentre as cominadas no tipo penal, dosar a sua quantidade entre o mínimo e máximo previsto, fazer inserir causas que possam aumentar ou diminuir a reprimenda, fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como analisar possível substituição por pena mais branda.

Cuida-se de critério em que o julgador possui discricionariedade regrada. Isso porque, embora tenha liberdade de escolha quanto à pena que irá aplicar, bem como sua quantidade, deve obediência a regras previstas no Código Penal.

Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei das Execuções Penais.

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão".

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF).

Deve o réu aguardar eventual recurso custodiado, tendo em vista que respondeu a

todo o processo nesta condição e, inalteradas as circunstâncias, persistem presentes os requisitos que ensejaram a prisão processual, especialmente após a condenação.

Após trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida com o réu, a qual certamente provém da atividade ilícita acima analisada.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Transitada esta em julgado, oficie-se para incineração total ou parcial das drogas como acima determinado e providencie-se o necessário quando ao perdimento do dinheiro, comunicando-se ao SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06). Após, archive-se.

P.I.C.

Francisco Morato, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA